

《【문제5.2】

<사례>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금 청구소송을 제기하였다. 제1심 소송 계속 중, 피고 乙은 `甲과 소를 제기하기 전에 이미 이 사건 분쟁에 대하여 법원에 소를 제기하지 않기로 합의(부제소특약)를 하였으므로 이 사건 소는 부적법하다`고 주장하며 소각하를 청구하였다. 그러나 제1심 법원은 부제소특약의 존재 여부 및 그 적법성에 대해 구체적으로 심리하지 아니한 채, 변론기일을 열어 곧바로 대여금 채권의 성립 여부 등 본안에 관한 심리를 진행하였다. 제1심 법원은 심리 결과 대여금 채권이 시효로 소멸하였다는 이유로 甲의 청구를 기각하는 본안판결을 선고하였고, 甲은 이에 불복하여 항소하였다. 한편, 또 다른 사건에서 원고 A는 피고 B를 상대로 손해배상 청구소송을 제기하여 심리가 진행 중이다. 그런데 소송 계속 중 B는 `A가 정신적 질환으로 인해 의사능력을 완전히 상실하였으므로 당사자능력에 흠결이 발생하였다`고 주장하였다. 제1심 법원은 이러한 당사자능력과 같은 소송요건의 존재 여부를 어느 시점을 기준으로 판단해야 하는지, 그리고 해당 소송요건의 존부에 대한 증명책임은 소송법상 누구에게 귀속되는지 검토하고 있다.

(물음2) A와 B의 소송에서 당사자능력 등 소송요건의 존재를 판단하는 기준 시점은 언제인지 설명하고, 소송요건의 존부에 대한 증명방법 및 증명책임의 분배 원칙에 대하여 기술하시오.》

<문제5.2의 물음2> 당사자능력 등 소송요건의 존재를 판단하는 기준 시점과 증명방법 및 증명책임의 분배 원칙

I. 문제의 제기

- 사안에서 원고 A와 피고 B 사이의 손해배상청구소송에서 피고가 원고의 당사자능력 흠결을 주장함에 따라 소송요건인 당사자능력 등의 존부를 판단하여야 하는 상황이다. 쟁점으로 <소송요건의 존부를 판단하는 기준 시점과 소송요건에 관한 증명방법 및 증명책임의 분배 원칙이 무엇인지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소송요건의 판단 기준 시점과 소송요건의 증명방법 및 증명책임의 분배 원칙을 기술한다.

II. 소송요건의 존재 판단 기준시점

1. 원칙 : 사실심 변론종결시

- 소송요건은 본안판결을 선고하기 위한 전제조건이므로, 소 제기 당시뿐만 아니라 판결을 선고하는 시점에도 구비되어 있어야 한다. 따라서 소송요건의 존부를 판단하는 표준적인 기준시점은 사실심의 변론종결시가 된다. 소 제기 당시에 소송요건에 흠결이 있었다더라도 사실심 변론종결시까지 보장되면 소는 적법해지며, 반대로 소 제기 당시에는 요건을 갖추었으나 소송 도중 흠결이 발생하고 변론종결 시까지 보장되지 않으면 부적법 각하된다.

2. 예외 : 소 제기시 등을 기준으로 하는 경우

- 일부 소송요건은 제도의 취지상 예외적인 기준시점을 갖는다. 예컨대 제소기간의 준수 여부는 소 제기시를 기준으로 판단하며, 관할권의 존부는 "민사소송법 제29조"에 따라 소를 제기한 때를 기준으로 확정되는 관할항정의 원칙이 적용된다.

III. 소송요건의 증명방법 및 증명책임

1. 소송요건의 증명방법

(1) 직권조사사항과 자료수집의 범위

- 당사자능력을 비롯한 대부분의 소송요건은 직권조사사항에 해당하므로 법원은 직권으로 조사를 진행하여야 한다. 이때 자료의 수집까지 법원이 직권으로 행하는 직권탐지주의가 적용되는지, 아니면 자료의 제출은 당사자에게 맡기되 조사만 직권으로 하는 직권조사주의가 적용되는지에 대해 "판례"는 소송요건의 성질에 따라 판단한다. 공익적 성격이 강한 당사자능력, 대리권 존부 등은 직권탐지주의가 적용된다.

(2) 자유로운 증명

- 본안의 사실인정은 엄격한 증명에 의하여야 하므로 법정의 증거방법에 제한을 받으나, 소송요건에 관한 사실은 소송절차에 관한 사실에 불과하므로 증거방법의 제한이 없는 자유로운 증명으로 족하다. 따라서 법원은 신문조서, 공문서 외에 간이한 방법으로 사실을 확인할 수 있다.

2. 소송요건의 증명책임 분배 원칙

(1) 적극적 소송요건

- 소가 적법하기 위해 존재해야 하는 요건인 당사자능력, 당사자자격, 재판권 및 관할권의 존재에 대해서는 원칙적으로 소를 제기한 원고가 그 존재에 대한 증명책임을 부담한다.

(2) 소극적 소송요건

- 소가 적법하기 위해 존재하지 않아야 하는 장애사유인 기판력의 저촉, 중복소제의 금지 위배, 부제소특약의 존재에 대해서는 소의 부적법을 주장하며 각하를 구하는 피고가 그 존재에 대한 증명책임을 부담한다.

IV. 사안의 적용

1. 당사자능력 판단 기준시점의 적용

- 원고 A는 소송 계속 중 정신질환으로 의사능력을 상실하여 당사자능력의 흠결 문제가 발생하였다. 당사자능력은 적극적 소송요건이자 직권조사사항이므로, 제1심 법원은 사실심 변론종결시를 기준으로 A의 당사자능력 유무를 판단하여야 한다. 만약 변론종결 당시에도 A가 당사자능력을 회복하지 못했거나 적법한 특별대리인 등의 수계 절차가 이루어지지 않았다면 소는 부적법 각하되어야 한다.

2. 증명방법 및 증명책임의 적용

- 당사자능력의 존부는 공익적 소송요건이므로 법원은 직권탐지주의에 따라 자유로운 증명방법으로 A의 의사능력 상실 여부 및 병원 진단서 등을 검토할 수 있다. 소송법상 적극적 소송요건인 당사자능력의 존재에 대한 최종적인 증명책임은 원고 A 측에 귀속되지만, 법원은 직권으로 의사의 감정을 명하는 등 사실 조사를 선행하여 절차적 하자를 치유할 수 있도록 조치하여야 한다.

V. 결론

- 당사자능력 등 소송요건의 존재를 판단하는 기준시점은 원칙적으로 사실심 변론종결시이다. 소송요건의 증명은 증거방법에 제한이 없는 자유로운 증명으로 가능하며, 당사자능력과 같은 적극적 소송요건의 존부에 대한 최종적인 증명책임은 소를 제기한 원고에게 귀속된다. 따라서 법원은 변론종결시를 기준으로 A의 의사능력 결여 상태를 자유로운 증명방법으로 심리한 후, 요건 흠결이 확정된다면 소를 각하하여야 한다.